

1503149-70.2021.8.26.0073

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO

Comarca: Avaré

Foro: Foro de Avaré

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... de São Paulo:

"Apelação Criminal -Tráfico de entorpecente- Nulidade do processo e da prova coligida porque a busca domiciliar fez-se sem autorização judicial -Inexistência Tráfico de entorpecente na modalidade "ter em depósito" é crime permanente - A ocorrência de flagrante delito justifica a busca domiciliar sem autorização judicial -Tipificação- A prova oral, a quantidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Avaré

Foro de Avaré

1ª Vara Criminal

Rua Abílio Garcia, 527, Avare-SP - cep 18706-047

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1503149-70.2021.8.26.0073 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503149-70.2021.8.26.0073

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2176125/2021 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 18788809 -

DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 1733/21/129 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 2176125 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 2176125 - DISE- DEL.SEC.AVARE, 1733/21/129 - DISE- DEL.SEC.AVARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBERT RAMOS FERREIRA e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO

VISTOS

ROBERT RAMOS FERREIRA e REGINALDO MOISÉS FERREIRA FILHO, já qualificado nos autos a fls. 11 e 16, foram denunciados pelo Ministério Público como incursos nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, na forma do art. 29 do Código Penal, com, sob a acusação de que no dia 29 de junho de 2021, por volta das 16h30min, na Rua Coriolano Maynardes Araújo, 38, Parque Gilberto Filgueira, nesta cidade e Comarca

de Avaré, previamente ajustados e com unidade de desígnios, tinham em depósito e vendiam 02 (duas) porções de cocaína, pesando 27,82g (vinte e sete gramas e oitocentos e vinte miligramas), conforme laudo de exame químico-toxicológico a fls. 140/143, substâncias estas que causam dependência, o que fazia em desacordo com norma legal ou regulamentar (portaria 344/98 SVS/MS).

Auto de prisão em flagrante delito e demais peças do inquérito policial (fls. 01/143). Notificados sobre as acusações que lhes são imputadas (fls. 288 e 290), os réus apresentaram defesa prévia (fls. 298). Não sendo o caso de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 31 de agosto de 2021 (fls. 303/305). Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas de acusação, uma testemunha de defesa e, ao final, os réus foram interrogados (fls. 363/364).

Em alegações finais orais, o Ministério Público discorreu sobre toda a prova produzida e pugnou pela procedência da ação a fim de condenar o réu nos termos da denúncia (fls. 368/373). A douta Defesa dos réus, por sua vez, em sede preliminar pleiteou pelo reconhecimento da nulidade processual por violação de domicílio dos réus, com a absolvição dos acusados com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a absolvição dos acusados em relação ao tráfico de drogas, nos termos do artigo 386, incisos I, II, IV, V ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteou pela desclassificação do delito para o crime de porte de drogas e, em caso de eventual condenação, pela aplicação da pena em seu patamar mínimo legal, pelo reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da lei de Drogas, bem como pela fixação do regime aberto e substituição da pena por restritivas de direitos (fls. 376/398).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e Decido.

De prôemio, a preliminar de nulidade de provas alegada pela Defesa não merece prosperar. A entrada dos policiais na residência do réu não ocorreu de forma irregular, tampouco o flagrante foi ilegal não havendo, pois, se falar em irregularidade e/ou nulidade.

Ora, o ingresso dos policiais na residência do réu, sem autorização judicial, não está eivado por qualquer mácula. Primeiramente, porque não há comprovação de que a entrada não foi permitida. De fato, não há qualquer menção nos autos de resistência ao ingresso dos agentes por parte dos residentes, mas há justamente o contrário, com os réus afirmando em audiência que o réu Reginaldo franqueou tranquilamente a entrada dos policiais.

Em adição, o artigo 5º, XI, da Constituição Federal prevê que a busca domiciliar não prescinde de mandado judicial, salvo nas hipóteses excepcionais, constitucionalmente previstas, dentre elas o caso de flagrante delito. Como é cediço, o ato análogo ao tráfico de entorpecentes é crime permanente e, em caso de flagrante de crime dessa natureza é possível a realização de busca domiciliar sem mandado judicial.

Assim, era perfeitamente lícito aos policiais, incumbidos do combate à criminalidade, adentrar na casa onde a droga estava sendo fracionada. Não se pode cogitar, por conseguinte, na ilicitude das provas obtidas, pois o momento consumativo do delito de traficância se prolonga no tempo. A respeito da prescindibilidade do mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, há sedimentada jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (RE nº 603.616/TO; Relator Ministro Gilmar Mendes). Nesse sentido, já se posicionou o Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Apelação Criminal -Tráfico de entorpecente- Nulidade do processo e da prova coligida porque a busca domiciliar fez-se sem autorização judicial -Inexistência Tráfico de entorpecente na modalidade "ter em depósito" é crime permanente - A ocorrência de flagrante delito justifica a busca domiciliar sem autorização judicial -Tipificação- A prova oral, a quantidade e a variedade de forma do entorpecente apreendido em poder dos réus asseguram que a droga se destinava à

venda . Consumação .Para a consumação do crime do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, de ação múltipla, é desnecessário surpreender o agente em ato de mercancia, bastando que haja conduta que se ajuste a um dos verbos do tipo penal (misto alternativo Ausência de elementos seguros a indicar que os acusados estivessem associados para traficar Liame subjetivo de caráter estável não caracterizado Recursos desprovidos" (Apelação Criminal n.º 990.08.160355-1 rel. Desembargador José Raul Gavião de Almeida) (g.n.).

Ora, finda a instrução processual, restou claro que a abordagem foi motivada pela suspeita de traficância.

Inquestionável que a ação dos agentes da lei se revestiu de fundada suspeita, em conformidade com o artigo 240, §2º, do Código de Processo Penal, sendo descabida a aventada ilegalidade da busca pessoal.

No mérito, examinada a questão à luz da prova produzida, é forçoso reconhecer que a denúncia procede integralmente.

A materialidade do delito restou configurada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência de fls. 03/05, pelos autos de exibição e apreensão (fls. 27), pelas fotografias de fls. 32/33, do laudo de constatação prévia de substância entorpecente (fls. 34/36), pelo laudo químico-toxicológico (fls. 140/143), bem como por toda prova oral produzida.

A autoria também é incontroversa.

A testemunha de acusação Edson Barca, policial civil, em juízo, afirmou que, por meio de campana, foi detectada movimentação típica de tráfico de drogas no local dos fatos. Disse que em nenhum momento os dois réus foram visto efetuando a venda e entrega da droga, mas foi possível notar que usuários adentravam o quintal, que é uma área que não tinha muro, pois a fachada era uma área aberta, entravam ali naquele espaço que era a garagem, ou mesmo dentro da casa, pois não era possível visualizar, permaneciam poucos minutos e depois saíam, em movimentação típica de tráfico. Relatou que as pessoas que frequentavam o local dos fatos tinham várias características comuns a usuários de drogas. Declarou que na data dos fatos receberam informações de que estaria ocorrendo o tráfico de drogas naquele local, e assim que pararam em frente ao imóvel, bateram na porta e foram recebidos pelo réu Reginaldo que franqueou a entrada dos policiais e, questionado, respondeu que não tinha drogas no local e não estava ocorrendo tráfico ali. Esclareceu que foi localizada dentro de uma lata que estava sobre o armário do quarto do réu Reginaldo uma substância entorpecente. Disse que obtiveram a informação de que a irmã de Reginaldo também usava o mesmo armário onde foi encontrada a droga, mas a lata com o entorpecente foi encontrada sobre o armário, e não dentro dele. Relatou que a irmã de Reginaldo informou que fazia algum tempo que não utilizava drogas. Informou que Robert estava dentro do imóvel no momento da ocorrência, onde também estavam a mãe dos réus, o Reginaldo e outras pessoas. Respondeu que o réu Robert informou que morava em outro local. Afirmou que ambos os réus informaram que faziam bicos e ajudavam como serventes, mas nada fixo. Acrescentou que havia um carro na garagem, mas não havia uma desproporção entre os bens localizados na casa e suas alegadas ocupações lícitas. Disse que reconhece o réu Reginaldo de outra ocorrência, mas não se recorda se era relativo a tráfico. Respondeu que não foi encontrado dinheiro na residência. Afirmou que foi encontrada uma única porção de cocaína dentro de uma embalagem plástica, e não foi encontrado nenhum outro apetrecho. Declarou que residiam no imóvel a mãe dos réus, a esposa do réu Reginaldo, Reginaldo, a irmã dos réus chamada Elisabete e algumas crianças. Informou que, durante as campanas, não chegaram a abordar os usuários que estavam frequentando o local dos fatos porque utilizam viatura velada, então isso acaba atrapalhando o serviço, e por isso não foi feita nenhuma abordagem.

A testemunha de acusação Diego do Amaral, policial militar, em juízo, declarou que receberam informações que davam conta de que os réus estavam praticando o tráfico e associação para o tráfico e inclusive abasteciam algumas "biqueiras" pela cidade. Informou que, embora o local fosse de difícil acesso, durante campana, notou grande movimentação de pessoas na residência dos réus, que são irmãos. Esclareceu que as casas ao lado da casa onde os réus eram muradas, e a dos réus era a única que não

tinha portão, então perceberam uma movimentação muito grande de pessoas. Relatou que sabiam que a guarda de drogas não era feita naquele imóvel, mas em uma mata perto do local dos fatos. Contou que obtiveram informações no sentido de que, naquele momento dos fatos, estaria ocorrendo tráfico de drogas no local dos fatos. Declarou que chegaram no local e lá estavam o réu Reginaldo, sua esposa, o réu Robert e uma criança, e era por volta de 16h, e todos estavam no sofá se alimentando. Disse que o réu Reginaldo franqueou por escrito a entrada na casa. Asseverou que foi-lhes dito que Robert não residia naquele local, mas nos dias das campanas e no dia dos fatos o réu Robert se encontrava no local. Afirmou que foi realizada uma busca minuciosa no quarto do réu Reginaldo, e havia um armário aberto de prateleiras e coberto só por uma cortina, e em cima desse armário havia uma lata de extrato de tomate pesada, em que havia arroz embaixo e em cima havia uma quantidade considerável de cocaína, e os réus disseram que não lhes pertencia. Afirmou que nesse momento, Elisabete, a irmã dos réus, chegou ao local e disse que fazia uso de cocaína, mas já fazia dois dias que não usava, e ela negou veementemente a propriedade daquela droga. Asseverou que a irmã dos réus disse na delegacia que os réus movimentavam grande quantidade de dinheiro e não tinham ocupação lícita. Afirmou que Elisabete disse que quando ia pegar algum pertence seu, via, por vezes, uma grande montante de dinheiro naquele armário, e logo depois o dinheiro era retirado de lá pelos réus. Relatou que acredita que os apetrechos eram guardados juntamente com o dinheiro em outro local, pois as informações davam conta de que os usuários compravam e a droga era pesada no local. Acrescentou que acredita que os réus, pela surpresa de Reginaldo, esqueceram aquela porção de droga em cima do armário, e por isso franqueou a entrada policial com tanta tranquilidade. Respondeu que acredita que a droga não era de Elisabete, pois ela demonstrou bastante veracidade em seus relatos, e a quantidade de droga encontrada é exorbitante para pertencer a ela, já que ela não tinha condições de adquirir drogas. Afirmou que os réus relataram que faziam bicos, mas durante as campanas observaram que os acusados não faziam outra coisa, permanecendo o tempo todo dentro de casa, e por isso acredita que eles não tem ocupação lícita alguma. Respondeu que, no momento da abordagem, estavam na casa Reginaldo, Robert, a mulher de Reginaldo e não se lembra se havia uma ou duas crianças. Alegou que Rogério não estava na casa no momento da abordagem e não o conhece. Informou que Reginaldo não ofereceu resistência durante a abordagem. Aduziu que não havia a possibilidade de abordar usuários durante a campana. Esclareceu que, no armário do quarto de Reginaldo havia várias prateleiras, e cada prateleira era usada por uma pessoa, mas ninguém disse quem usava a parte onde foi encontrado o entorpecente. Declarou que foi feita uma busca pessoal nos acusados, mas nada de ilícito foi encontrado. Informou que o réu Robert disse que morava no bairro Vila Jardim, que fica próximo dali, mas foi apurado pelas campanas e no dia dos fatos que Robert não saía do local dos fatos. Relatou que sabiam que os réus guardavam os materiais usados no tráfico no mato, mas não localizaram.

A testemunha de defesa Rogério Pereira Ramos, em juízo, declarou que o imóvel em que o réu Robert mora é de sua família. Alegou acreditar que Robert morava lá com outra irmã de nome Sara. Aduziu que tinha pouco contato com Reginaldo, e nunca o viu trabalhar. Prestou relatos sobre a vida pregressa dos acusados.

Em sede de interrogatório judicial, o réu Robert Ramos Ferreira, negou os fatos. Alegou que tinha acabado de chegar ao local, pois passou ali para almoçar por volta das 16h. Disse que estava fazendo bicos, mas às vezes não consegue trabalhar, pois não consegue movimentar a mão por conta de tendinite, mas estava soltando pipa na data dos fatos. Respondeu que não falou nada com a polícia, pois eles nem falaram consigo. Relatou que o quarto onde foi localizada a droga ficavam Reginaldo e sua mulher, Tainá, e Elisabete frequentava o quarto também, pois ela dormia na sala e guardava as roupas dela no armário do quarto de Reginaldo. Confirmou que Elisabete e Reginaldo são usuários de cocaína. Alegou que residia na Rua Ribeirão Vermelho do Sul, na Vila Jardim. Respondeu que não deixava nada no quarto de Reginaldo e tampouco o usava. Declarou que morava com a irmã Sara e três sobrinhos, na casa dos fundos da Rua Ribeirão Vermelho do Sul, pois a casa da frente é de sua prima, e no terreno tem três casas da família. Respondeu que, no momento em que a polícia

chegou no imóvel de sua mãe, estava almoçando na sala, e ficou sentado no sofá durante a busca que a polícia realizou. Alegou que não sabia que havia drogas na casa, e tampouco seu irmão. Aduziu que sua família ficou bem tranquila quando a polícia entrou na casa. Contou que disse na delegacia que não sabia de quem era a droga porque não morava ali. Afirmou que, na delegacia, os policiais o informaram sobre a denúncia que haviam feito sobre si e o irmão. Disse que seu irmão já foi usuário de drogas, mas na data dos fatos acha que seu irmão não estava usando entorpecentes. Relatou que já experimentou droga, só usou maconha na infância, mas hoje em dia não usa mais. Respondeu que saiu do serviço porque preferia trabalhar com seu tio e era todo dia, mas às vezes trabalhava por três meses seguidos e depois ficava duas semanas parado. Informou que tem tendinite na mão esquerda há quase um ano e tuberculose, e faz tratamento para esta há um mês. Disse que tomou ciência do depoimento de sua irmã Elisabete apontando ambos os réus como traficantes, e que ela disse que não falou nada daquilo, estava nervosa, e os policiais teriam condicionado a assinatura do termo à liberação dela, e por isso ela teria assinado. Relatou que sua irmã Elisabete e a mulher de Reginaldo fazem cabelo e unhas para as amigas delas naquele local. Afirmou que sua irmã Elisabete guardava utensílios e produtos de beleza no armário do quarto de sua mãe. Respondeu que o veículo Gol encontrado na residência pertence a sua avó, e ela o financiou, pois precisa ir bastante para São Paulo por conta do marca-passo que tem no coração. Alegou que não usava o armário do quarto de Reginaldo e sequer entrava nele, pois é um local íntimo. Disse que Elisabete guardava coisas dela naquele mesmo armário. Narrou que não tem certeza de quem é a droga encontrada no quarto de Reginaldo.

Em sede de interrogatório judicial, o réu Reginaldo Moisés Ferreira Filho negou os fatos. Alegou que está fazendo bicos com seu pai, como pedreiro. Aduziu que a droga que foi encontrada pertence a sua irmã Elisabete, e não sabia que o entorpecente estava ali. Disse que trabalhava com venda de frutas pela cidade inteira na época dos fatos, com uma pessoa chamada Leandro, e vendia furtas, verduras e legumes com um veículo Belina. Relatou que estava trabalhando como "motoboy" na data dos fatos, e os policiais entraram após ter dito que podiam adentrar o imóvel. Disse que ficou surpreso com a localização da droga. Contou que sua irmã Elisabete disse que a droga era dela, e que ela também foi para a delegacia. Disse que atendeu a polícia educadamente "porque não devia". Confirmou que Elisabete fazia uso compartilhado do guarda-roupas onde foi encontrada a droga. Esclareceu que as prateleiras do guarda-roupas são pequenas. Disse que não sabia da existência de drogas no local dos fatos. Afirmou que Elisabete lhe perdeu perdão após prestar o depoimento na delegacia. Relatou que Elisabete era usuária de drogas, e veio de São Paulo por conta do vício, e usava cocaína e álcool. Disse que também usava drogas, e combinou com Elisabete de comprar droga em um lugar que indicou, mas não sabe nada exatamente sobre essa droga encontrada no armário de seu quarto. Respondeu que sua mãe e sua esposa são manicures e sua esposa é cabeleireira, e atendiam na sala do imóvel as amigas e membros da família por meio de agendamento pelo "WhatsApp". Narrou que, na data dos fatos, residiam no imóvel, além de si, sua mãe, sua mulher, seu padrasto e sua irmã, sendo que Robert morava em outro local com sua irmã Sara e com seus sobrinhos. Acrescentou que o automóvel Gol, de cor vermelha, pertence a sua avó, e tem data de fabricação por volta de 2002. Relatou que Leandro deporia em juízo, mas ele não compareceu porque está com problemas. Contou que atualmente está trabalhando como servente de pedreiro com seu pai, e ganha sessenta reais por dia. Pelo conjunto probatório que se apresenta, a partir da prova oral coligida, percebe-se que a condenação é medida de rigor, pois a negativa oferecida pelos réus soa por demais inconvincente e completamente desamparada de um mínimo de suporte indiciário.

Pois bem, a tipificação do crime de tráfico de drogas in casu extrai-se das circunstâncias da prisão e da quantidade de droga apreendida.

Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova. No caso dos autos, os elementos de convicção evidenciam a prática da mercancia ilícita.

Nesse contexto, o edito condenatório é imperativo, sobretudo diante do teor dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, pois confirmaram os termos da inicial acusatória e evidenciaram a responsabilidade criminal dos acusados no que tange ao crime de tráfico. Por isso, força convir que os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade e servem, perfeitamente, para supedâneo da prolação de sentença condenatória, depoimentos estes que, em Juízo, harmônicos entre si, sintonizaram-se com os seus depoimentos prestados extrajudicialmente.

De mais a mais, os policiais ouvidos em juízo foram uníssonos em relatar que, por meio de campanas, notaram a frequente e grande movimentação na residência dos réus, e que as pessoas que se dirigiam ao local iam à região da garagem ou no interior da residência e ficavam poucos minutos e depois iam embora. Acrescentaram que as pessoas que frequentavam o local dos fatos apresentavam características típicas de usuários de drogas. Isso também afasta a versão dos réus, no sentido de que a genitora deles e a mulher do réu Reginaldo atendiam mulheres como manicures e cabeleireira, pois a variedade de pessoas observada pelos policiais obviamente difere de tais alegações. Os policiais narraram os fatos de forma coerente e linear, descrevendo a ocorrência de forma idêntica ao quanto narrado em fase policial, sendo certo que os depoimentos dos agentes da Lei, sejam civis, militares, ou mesmo guardas municipais, têm valor igual aos depoimentos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros da polícia, sendo totalmente descabido eventual preconceito acerca de seus testemunhos.

E também não se vislumbra ilegalidade ou inconstitucionalidade no depoimento de tais agentes, pois, na condição de testemunhas, como qualquer outra pessoa (CPP, art. 202), prestam compromisso, nos termos da lei, e estão sujeitos às penas por falso testemunho que, como visto, não tinham razão para incriminá-lo, graciosamente, tanto que foram ouvidos em audiência e não foram contraditados no momento oportuno (CPP, art. 214). Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos milicianos, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendiam incriminar injustamente o réu ou em faltarem com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Neste sentido:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846) (g.n.)

Sob outra prisma, a alegação do réu de que é usuário de drogas, por si só, não retira a convicção de que também traficaria. Prova do alegado vício era ônus que lhe pertencia do qual, porém, não se desincumbiu. Não conseguiu sequer comprovar a origem lícita do dinheiro apreendido em sua residência, quiçá sua renda mensal como servente de pedreiro. Ademais, a quantidade da droga apreendida - 02 (duas) porções de cocaína, pesando 27,82g (vinte e sete gramas e oitocentos e vinte miligramas) -, bem como a forma como estavam acondicionadas, mostram-se demasiadas para quem pretende o reconhecimento do uso próprio. Neste sentido, são as reiteradas decisões da E. Corte Bandeirante:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Pedido de desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, alegando não ter ficado comprovada a traficância. IMPOSSIBILIDADE. Presentes a autoria e a materialidade - Reconhecimento do tráfico pelas circunstâncias da ocorrência - Usuário também pode ser traficante - Existência de denúncia anônima apontando o apelante como traficante no local
Recurso não provido. TJ-SP - Apelação: APL 00035460920128260369 SP 0003546-09.2012.8.26.0369. Julgamento: 19/08/2014 (grifo nosso).

...

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Impetração visando a absolvição pela fragilidade probatória Pedido final de desclassificação ou substituição da pena. IMPOSSIBILIDADE. Presentes a autoria e a materialidade - Reconhecimento do tráfico pelas circunstâncias da ocorrência - Usuário também pode ser traficante Guardas civis que visualizaram o momento em que o apelante jogou as drogas ao chão Inviável o aumento da redução e a substituição da pena - Recurso não provido. TJ-SP - Apelação: APL 00000372620128260125 SP 0000037-26.2012.8.26.0125. Julgamento:12/08/2014 (grifo nosso)

Soa ainda mais fantasiosa a afirmação dos réus de que sua irmã Elisabete teria dito que a droga não lhe pertencia apenas para que ambos fossem acusados de tráfico, e que depois Elisabete teria "pedido perdão" pelo depoimento, e que tais declarações em solo policial teriam sido prestadas como condição para que pudesse ir embora da delegacia. Ora, não é crível que funcionários públicos realizem tais práticas para prejudicar alguém ou para justificar sua atuação perante a sociedade. Com efeito, ambos afirmaram que havia muitas informações acerca da traficância naquele local. Ademais, como é sabido, o delito de tráfico de drogas não exige, para a sua configuração, a venda propriamente dita do entorpecente, pois o tipo penal inserto no artigo 33 da lei antidrogas fez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aqueles de "ter em depósito" e "trazer consigo". Confira-se: "Anoto, ainda, que para configuração do crime do artigo 33, da Lei de Drogas imputado aos réus, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando que os agentes tragam consigo, tenham em depósito ou guardem a substância entorpecente, não se exigindo a tradição, para consumação do delito (RJTJSP vol. 97, página 512)" (9174718-08.2009.8.26.0000, Rel. Marco Antonio Marques Maia, 6ª Câmara de Direito Criminal, 17/09/2009)" (grifo nosso).

...

"O crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663) (grifo nosso)

Desta feita, os elementos de convicção evidenciam a prática da mercancia ilícita perpetrada pelos réus quer seja pela quantidade de drogas apreendidas, sua forma de embalagem, natureza das substâncias e também, como não poderia deixar de ser, pela prova testemunhal sendo, pois, a absolvição meta impossível de ser alcançada. Por fim, entendo que também restou isolada a versão apresentada pelo réu Robert, de que moraria em outro bairro, pois as informações colhidas nas campanhas realizadas davam conta de que o acusado não saía daquele local. Ambos os réus foram desmentidos pelos militares, sendo certo que claramente esconderam a verdade em juízo, invertendo a ordem legal, ou seja, os réus tenta se passar de perseguidos e vítimas dos militares que, por outro lado, se transformam em algozes e infratores. Reputo inviável tal solução, conforme argumentou o eminente Desembargador Souza Nery na Apelação Criminal nº. 990.10.311699-2, onde consta: "Aceitar-se a versão do réu seria fechar os olhos a uma realidade manifesta e dar as costas ao óbvio, em total e completo desapego às normas genéricas da verdade e do bom-senso, que emanam sem nenhuma dúvida dos autos. Nada obstante deva estar o julgador sempre atento e dedicado às teses defensórias, verdade é que há um momento em que as versões não podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto que representam sua irre realidade. O julgador, então, que é e deve ser homem de bom-senso e com preocupação com a realidade ideal, pode e deve sempre afastar as teses sem qualquer cunho de razoabilidade, como aqui. Dar-se crédito àquele que mantém na sua posse considerável quantidade de droga, em plena e objetiva ação delituosa, em detrimento das palavras de agentes de lei, que cumpriam seu papel de proteger a sociedade, seria inverter de tal forma os valores, que se deixaria em descrédito a própria justiça. Tanto não é possível, exatamente porque as escusas são para livrá-lo da responsabilização, que é imperiosa, todavia. Ou valem as palavras dos Policiais, ou se estará dando crédito maior a quem possui, mantém em depósito e comercializa drogas, em plena ação delituosa. No confronto, portanto, não há como se inverter

posições. Na defesa da sociedade e de todos os homens de bem, que querem ver a Polícia e o Judiciário atuando no combate ao crime e nesta nefasta distribuição de drogas”.

Diante do exposto, por esses fundamentos e mais o que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO os réus ROBERT RAMOS FERREIRA e REGINALDO MOISÉS FERREIRA FILHO, qualificados nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 29 do Código Penal. Resta dosar a pena pelo critério trifásico adotado pelo Código Penal.

Réu Robert Ramos Ferreira:

Na primeira fase, em observância ao artigo 42 da Lei de Drogas, bem como aos elementos preconizados pelo artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu é primário (F.A. a fls. 340/342 e certidões a fls. 343/344), de forma que fixo a pena-base no valor mínimo legal, resultando em cinco anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal, inclusive valor do dia-multa, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60). Na segunda fase de dosimetria, ausentes agravantes ou atenuantes. Por fim, na terceira fase, entendo que se faz necessário o reconhecimento da diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, pois o réu é primário e não há nos autos notícias de sua participação em associação criminosa. Assim, diminuo a pena anteriormente imposta em 2/3 (dois terços) resultando em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Não estão presentes mais causas de aumento ou de diminuição da pena. Portanto, fixo em definitivo a pena a cumprir de 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO e PAGAMENTO DE 166 (cento e sessenta e seis) DIAS-MULTA, com o dia unitário no piso mínimo legal.

Pese contrário ao entendimento deste Magistrado, necessário apontar que o regime inicial deverá ser o ABERTO, conforme recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exarado no bojo do HC n. 596603-SP, no qual houve determinação para imposição de regime inicial aberto para cumprimento de pena, inclusive em relação a fatos futuros, na hipótese de condenação por tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, §2º, do Código Penal. Confira-se (...) Aos condenados que atualmente cumprem pena e aos que vierem a ser sancionados por prática do crime de tráfico privilegiado, determinar que não se imponha – devendo haver pronta correção aos já sentenciados – o regime inicial fechado de cumprimento da pena. (STJ - HC: 596603 SP 2020/0170612-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 04/08/2020).

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal - HC 118.533 - reconheceu que o delito em questão não é mais hediondo, entendo viável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Desta forma, faço a substituição da pena privativa de liberdade anteriormente fixada por duas restritivas de direitos. Assim sendo, observado o disposto pelo artigo 44, parágrafo 2º, 2ª parte e na forma dos artigos 45, parágrafo 1º e 46, todos do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam, a de Prestações de Serviços à Comunidade e de Prestação Pecuniária, por se revelarem as mais adequadas ao caso, sendo aquela consistente em tarefas gratuitas a serem desenvolvidas, pelo prazo da condenação, junto a entidade determinada pelo juízo da execução, devendo ser cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, que será distribuída e fiscalizada, de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do condenado, sem prejuízo da multa já fixada e a prestação pecuniária no valor de um terço do salário mínimo nacional da época da infração penal, sendo destinada para entidade beneficente também indicada pelo juízo das execuções penais.

Ao Juízo da Execução, após o trânsito em julgado desta decisão, caberá fiscalizar a entidade beneficiada com a prestação de serviços, a qual deverá ser comunicada a respeito, através de seu Representante, com remessa de cópia da presente sentença, incumbindo-lhe encaminhar mensalmente relatório circunstanciado, bem como a qualquer tempo, comunicar sobre a ausência ou falta disciplinar da condenada, consoante disposto pelo artigo 150 da Lei nº 7.210/84. Deverá, ainda, ser cientificado que a condenada é facultada cumprir a pena substitutiva em menor tempo (artigo 55 do Código Penal), sendo que, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade

fixada ou restante.

De acordo com o artigo 387, parágrafo único do CPP, inalterados os requisitos e não existindo prisão provisória decretada, o réu poderá apelar em liberdade.

Réu Reginaldo Moisés Ferreira Filho:

Na primeira fase, em observância ao artigo 42 da Lei de Drogas, bem como aos elementos preconizados pelo artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu é reincidente (F.A. a fls. 345/348 e certidões a fls. 349/351), circunstância que será valorada na próxima fase da dosimetria. A quantidade de droga não é grande. Assim, fixo a pena-base no valor mínimo legal, resultando em cinco anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal, inclusive valor do dia-multa, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60). Na segunda fase de dosimetria, concorrem a agravante da reincidência (fls. 349/350 - proc 1500395-92.2020.8.26.0073) e a atenuante da menoridade relativa (fls. 16), motivo pelo qual efetuo a compensação, em observância à jurisprudência das Cortes Superiores. Desta feita, mantenho a pena no quantum fixado na fase anterior. Não estão presentes outras agravantes ou atenuantes. Por fim, na terceira fase, entendo que não existem causas de aumento ou de diminuição da pena. Não incide a benesse prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, pois o réu não preenche todos os predicados legalmente previstos. Com efeito, as circunstâncias da prisão não deixam dúvida de que o réu se dedicava à atividade criminosa, já que a reincidência no delito de tráfico de drogas indicam a responsabilidade penal do réu. A este teor: "Não há ilegalidade na negativa de aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, porquanto a quantidade e a natureza da substância apreendida levaram à conclusão de que o paciente se dedica a atividades delituosas, ou seja, não se trata de traficante ocasional" (HC 297447/RS, Ministro JORGE MUSSI, DJe 13/11/2014). E nem se alegue possível bis in idem relativo ao aumento da pena pela reincidência e a não aplicação do aludido redutor, uma vez que este deixou de incidir também em virtude da dedicação às práticas delitivas, tudo em fases distintas da dosimetria. Confira-se: "A valoração da reincidência na segunda etapa da dosimetria, como circunstância agravante, não é incompatível com a sua utilização, na terceira fase, para afastar a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porquanto o referido instituto jurídico é sopesado com finalidades distintas em cada fase de fixação da pena, justamente para se alcançar a justa e correta reprimenda necessária para a reprovação e prevenção do delito perpetrado. Precedentes" (HC 214069/SP - Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ - Sexta Turma - DJe 29/11/2013). Portanto, o réu não pode ser beneficiado pelo §4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Desta forma, fixo em definitivo a pena a cumprir de 05 (cinco) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 500 (quinhentos) DIAS-MULTA, com o dia unitário no piso mínimo legal.

Diante do disposto no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei nº 8.072/90, os réus deverão iniciar o cumprimento da pena em regime FECHADO. O restante da pena e eventuais benefícios legais deverão ser objeto de análise do juízo das execuções.

Inviável a substituição por pena restritiva de direitos, seja pelo fato de estarem ausentes os requisitos previstos nos artigos 44, III, e 77, II, ambos do Código Penal, seja porque o art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 estabelece que a reprimenda por crime de tráfico de drogas deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, seja, finalmente, porque o art. 44, caput, da Lei nº 11.343/2006, são expressos ao proibir referido benefício. Filio-me ao entendimento que sustenta a constitucionalidade de tais dispositivos, pelas seguintes razões, algumas delas retiradas da Arguição de Inconstitucionalidade no HC 120.353-SP, julgada em 04.11.2009 pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, Rel. originário Min. Og Fernandes, Rel. para acórdão Min. Ari Pargendler: i) o art. 5º, inciso XLVI, da CF/88, determina que a lei regulará a individualização da pena; ii) o art. 5º, inciso XLIII, da CF/88, estabelece que a lei deverá dispensar tratamento mais gravoso ao crime em questão, destacando também a importância da repressão a esse delito no art. 5º, inciso LI, o qual autoriza a extradição de brasileiro naturalizado comprovadamente envolvido com tráfico de drogas; iii) é perfeitamente possível que o legislador ordinário proíba a substituição da pena por restritiva de

direitos, tanto que o art. 44, do CP, veda o benefício para todos os crimes praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa ou com pena superior a 04 anos, ou, ainda, no caso de ser o agente reincidente em crime doloso; iv) o Brasil assinou tratados internacionais se comprometendo a combater o tráfico de drogas; v) o crime de tráfico de drogas, além de ser equiparado a hediondo e ser a principal causa de inúmeros outros delitos patrimoniais, gera efeitos nefastos para a sociedade e para as famílias de bem, de modo que a concessão do benefício, além de ser, no meu entender, incompatível com a sua gravidade, não se mostraria suficiente para a prevenção ou reprovação do delito (CP, art. 59, in fine), gerando ofensa ao disposto no art. 44, III, do CP, além de verdadeira sensação de impunidade nesta pequena e interiorana cidade de Avaré.

De acordo com o artigo 387, parágrafo único do CPP, inalterados os requisitos e não existindo prisão provisória decretada, o réu poderá apelar em liberdade.

Conforme art. 63 da Lei nº 11.343/06 c/c art. 91 do CP, decreta o perdimento de tudo quanto apreendido neste processo. Não tendo havido controvérsia, no curso do processo, sobre a natureza e a quantidade da substância entorpecente ou sobre a regularidade do laudo respectivo, fica determinado, desde já, sua destruição por incineração, na forma da legislação vigente (Lei n. 11.343/06, arts. 33, §§ 1º e 2º, e 58, §1º), no prazo máximo de 30 (trinta) dias, preservando-se fração suficiente para eventual contraprova. Comunique-se à autoridade de polícia judiciária competente, caso isso ainda não tenha sido providenciado.

Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente, adotem-se as seguintes providências: (a) expeça-se guia de execução (definitiva, se o caso) do condenado; (b) proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, em conformidade com o disposto no artigo 686, do Código de Processo Penal; (c) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando sua condenação, com a devida identificação dele, acompanhada de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto no art. 15, III, da Constituição da República c/c o art. 71, §2º, do Código Eleitoral; (d) oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias; (e) efetuem-se as averbações de praxe (NSCGJ, Cap. V, itens 22, d, e 23). Custas processuais nos termos da lei. P.I.C. Avare, 16 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA